

1500564-85.2020.8.26.0556

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sergio Augusto de Freitas Jorge

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... celular não havia conteúdo relativo ao tráfico de drogas, mas apenas algumas imagens e conversas trocadas com conhecidos sobre entorpecentes, já que faz uso de tais substâncias. Nunca teve envolvimento com o narcotráfico. Esclareceu que na data do ocorrido realizava um churrasco em sua residência e alguns vizinhos se sentiam incomodados com o som alto das festas que organizava no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

2ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses nº 1998

CEP: 14801-425 - Araraquara - SP

Telefone: (16) 3336-1034 - E-mail: araraq2cr@tjsp.jus.br

1500564-85.2020.8.26.0556 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500564-85.2020.8.26.0556

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX ALBERTO BENEDITO

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Sergio Augusto de Freitas Jorge

Vistos.

ALEX ALBERTO BENEDITO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, pois, no dia 21 de novembro de 2020, por volta das 19:00 horas, durante estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 06/2020), na Avenida José Cendon Farto, nº 226, Jardim Roberto Selmi Dei, nesta cidade e comarca, mantinha em depósito, para fins de tráfico, 2 porções de cocaína, com peso líquido de 75,38 gramas, e 2 porções de maconha, com peso líquido de 32,59 gramas, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado o acusado (fl. 173) e apresentada defesa preliminar (fls. 208/209), a denúncia foi recebida (fls. 210/211). O acusado foi citado (fl. 225).

Na fase de instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela Acusação, sendo o réu interrogado ao final (fls. 227/230).

Em debates orais, a DD. Representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, ao passo que o Ilustre Defensor Público postulou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06 ou, em caso contrário, o afastamento da majorante do art. 40, inciso III, da mesma lei e a aplicação do privilégio, com a fixação da pena no mínimo legal, em regime prisional inicial aberto, e a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos (fls. 227/230).

É o relatório.

DECIDO.

A acusação é parcialmente procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva foi aferida sobretudo pelo teor do auto de exibição e apreensão (fls. 07/08) e dos laudos de constatação provisória (fls. 10/14) e definitiva de entorpecentes (fls. 71/72 e 73/75), com resultados positivos para cocaína e THC (maconha), bem como do laudo de exame pericial do celular apreendido (fls. 103/147) e da informação policial com extração de conteúdo do aparelho (fls. 189/199).

A autoria do delito, por seu turno, foi evidenciada pelo conjunto da prova oral colhida no curso da ação penal e pelos demais informes coligidos na fase inquisitiva.

Em sede policial, o acusado declarou ser usuário de cocaína e maconha, mas negou a propriedade dos entorpecentes apreendidos em sua casa na data dos fatos. Alegou que no imóvel também residiam os indivíduos Igor e Vanderlei, não sabendo precisar de quem eram as drogas. Já o numerário localizado em seu poder era proveniente da venda de uma motocicleta (fls. 04 e 76).

Em juízo, tornou a negar a imputação, mas modificou sua versão e passou a afirmar que, na data mencionada, estava em frente à sua casa com seu amigo Vanderlei quando ambos foram abordados por policiais militares. Tinha consigo a quantia em dinheiro de R\$ 20,00, oriunda da venda de uma moto, e um celular, que foram apreendidos. Informou aos policiais que havia entorpecentes em sua residência e os autorizou a ingressar no imóvel, onde foram encontradas porções de cocaína e maconha. Negou ter admitido aos policiais a destinação das drogas para a venda, pois eram para o seu próprio consumo. Tampouco lhes disse que havia escondido entorpecente perto de uma caixa d'água existente nas proximidades de sua casa e não os levou a esse local. Aduziu que em seu celular não havia conteúdo relativo ao tráfico de drogas, mas apenas algumas imagens e conversas trocadas com conhecidos sobre entorpecentes, já que faz uso de tais substâncias. Nunca teve envolvimento com o narcotráfico. Esclareceu que na data do ocorrido realizava um churrasco em sua residência e alguns vizinhos se sentiam incomodados com o som alto das festas que organizava no local. Confirmou que tem o apelido de "Neguinho" (cf. gravação audiovisual de fls. 227/230).

Ocorre que, apesar das versões exculpatórias exaradas pelo réu nas ocasiões em que ouvido, o arcabouço probatório coligido durante a persecutio criminis contém elementos seguros e aptos a demonstrar a sua responsabilidade, na espécie.

Assim é que os policiais militares Becassi e Haddad relataram que, na época dos

fatos, havia informações no meio policial dando conta da prática do tráfico de drogas no imóvel mencionado. Na data em questão, durante patrulhamento, viram o acusado sentado na calçada, o qual, ao avistar a aproximação da viatura policial, levantou-se rapidamente, o que lhes despertou suspeita. Efetuaram a abordagem do réu e, em busca pessoal, localizaram em seu bolso certa quantia em dinheiro e um celular, que foram apreendidos. O acusado disse que em sua casa havia entorpecentes e lhes franqueou a entrada no imóvel. No quintal havia um outro indivíduo, também abordado, mas nada de ilícito foi com ele encontrado. Já no interior da casa, na sala e na cozinha, foram apreendidas 2 porções de maconha e uma outra de cocaína. O imputado ainda lhes revelou que ele e um outro rapaz escondiam entorpecente perto de uma caixa d'água situada a cerca de 200 ou 300 metros da residência. Dirigiram-se a esse local e ali foi encontrada, sob uma pedra, uma sacola contendo uma porção maior de cocaína. Indagado, o réu admitiu a propriedade de todos os entorpecentes localizados, dizendo que eram destinados à comercialização, mas não deu explicação sobre a origem do numerário. O terceiro indivíduo não foi localizado nem identificado. Esclareceram que, segundo moradores do bairro, havia movimentação anormal de pessoas na residência do réu, inclusive durante a madrugada (cf. gravação audiovisual de fls. 227/230).

Becassi ainda acresceu que o acusado estava bastante nervoso e apresentou versões contraditórias sobre os entorpecentes apreendidos na ocasião.

Como se vê, o quadro probatório é sólido e não deixa dúvidas acerca da conduta delituosa do réu. Os elementos de convicção produzidos na fase policial e em juízo revelam-se firmes e substanciais, apontando-o com segurança como agente criminoso, no caso vertente.

Na hipótese em exame, a conclusão de que as drogas se destinavam ao comércio ilícito e ao fornecimento a terceiros é obtida sobretudo pela natureza, diversidade e forma de acondicionamento dos tóxicos apreendidos (2 porções de cocaína, com peso líquido total de 75,38 gramas, e outros 2 invólucros plásticos de maconha, com peso líquido total de 32,59 gramas, já embalados e prontos para a revenda e entrega a terceiros - cf. auto de fls. 07/08, fotografias de fls. 13/14 e laudos de fls. 10/14, 71/72 e 73/75).

Também houve a apreensão em poder do acusado, no mesmo contexto fático, de um aparelho celular (utilizado como instrumento do crime) e de quantia em dinheiro (R\$ 20,00), certamente relacionada à prática ilícita em questão (cf. auto de fls. 07/08 e guia de fl. 70).

Note-se, a propósito, que o imputado não apresentou nenhuma prova cabal da suposta origem lícita do referido numerário, mas apenas a alegação vaga e genérica de que era proveniente da suposta venda de uma motocicleta.

No tocante ao celular utilizado pelo réu, o exame pericial realizado no aparelho e a informação policial dele decorrente revelaram a existência de várias imagens de entorpecentes, bem como de diversas mensagens claramente relacionadas ao comércio espúrio por ele praticado, consoante se depreende do teor dos diálogos mantidos com os contatos "Dri Neguinho", "Celião", "Edson", "Cris da 40", "Caio Black", "Erika", "Gui" e "Otávio" (cf. laudo de fls. 103/147 e informação policial de fls. 189/199).

Vale realçar que, ao ser indagado, o acusado chegou a admitir aos castrenses atuantes na ocorrência tanto a propriedade dos entorpecentes apreendidos em sua casa e nas proximidades do local quanto a sua destinação à comercialização.

Além disso, no meio policial já havia informações dando conta da frequente prática do tráfico de drogas no local dos fatos e nas suas imediações, consoante se infere do teor dos depoimentos dos milicianos ouvidos em solo judicial e dos documentos de fls. 80/94, que apontam a existência de diversas denúncias alusivas a tal prática

ilícita naquele mesmo imóvel e, na maioria delas, contendo expressa menção a Alex "Neguinho", apelido confirmado pelo próprio réu em juízo.

Tais aspectos, examinados de forma conjunta, afastam a veracidade das frágeis versões exculpatórias exaradas pelo réu e confirmam a ocorrência, na espécie, da guarda e da manutenção em depósito das drogas para fins da mercancia maldita.

Sabe-se, outrossim, que, para a configuração do delito de narcotráfico, não se exige qualquer ato de efetiva entrega de drogas, bastando que o agente transporte, traga consigo, guarde ou mantenha em depósito as substâncias entorpecentes, sendo inexigível a traditio para fins de consumação do crime (RJTJSP 97/512).

Afasta-se, por conseguinte, o pleito de desclassificação delitiva formulado pela Defesa Técnica, uma vez que todas as circunstâncias do fato acima mencionadas indicam de modo claro e estreme de dúvidas que os entorpecentes apreendidos eram pertencentes ao réu e se destinavam, efetivamente, à ilícita revenda e ao fornecimento a terceiros – ainda que de forma gratuita -, não sendo unicamente para o uso próprio do imputado.

É consabido, ademais, que a mera condição de usuário de tais substâncias não exclui, por si só, a prática do narcotráfico, pois é fato comum o usuário dedicar-se ao comércio nefasto ou à simples guarda temporária da droga para terceiro a fim de assim quitar suas dívidas com outros traficantes ou mesmo amealhar recursos para poder sustentar o próprio consumo pessoal.

Demonstradas, portanto, a materialidade e a autoria do delito imputado ao réu, passo à dosimetria das penas a lhe serem aplicadas.

Ante a consideração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, e sendo todas elas favoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase da dosimetria penal, descabe falar-se na incidência da agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, pois, embora não haja dúvida de que o crime foi cometido durante o período de calamidade pública decretada em face da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), tal circunstância em nada contribuiu para a prática delitiva, razão pela qual, ausente o nexo causal, deve ser afastada a agravante em questão. Confira-se:

"Na segunda fase do cálculo, é de rigor o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Para exata compreensão do tema, confira-se ensinamento de Guilherme de Souza Nucci: "53. Situação de desgraça particular ou calamidade pública: mais uma vez o legislador pretende punir quem demonstra particular desprezo pela solidariedade e fraternidade, num autêntico sadismo moral, aproveitando-se de situações calamitosas para cometer o delito. Vale-se da fórmula genérica e depois dos exemplos específicos. Constituem os gêneros da agravante: a) calamidade pública: que é a tragédia envolvendo muitas pessoas; b) desgraça particular do ofendido: que é a tragédia envolvendo uma pessoa ou um grupo determinado de pessoas. Como espécies desses gêneros temos o incêndio, o naufrágio e a inundação, que podem ser ora calamidades públicas, ora desgraças particulares de alguém. Ex: durante a inundação de um bairro, o agente resolve ingressar nas casas para furtar, enquanto os moradores buscam socorro." (in Código Penal Comentado, 20ª edição, Editora Forense, 2020, pg. 401). No caso concreto, embora incontestemente o estado de calamidade pública, não se verifica que o acusado tenha se aproveitado dessa situação para a prática do crime. A conduta do réu, que já não se encontrava em isolamento social, por ser morador de rua, de subtrair os objetos do interior de um carro estacionado em via pública não se amolda a exemplos hipotéticos de quem se aproveita de uma desgraça particular ou coletiva, como

incêndio, enchentes, acidentes automobilísticos, entre outros, para praticar crimes contra vítimas que se encontram em posição de maior vulnerabilidade decorrente dessas situações” (TJSP - Apelação nº 1510214-73.2020.8.26.0228 - 11ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Xavier de Souza - j. 14.09.2020).

Por fim, na derradeira etapa do procedimento trifásico, não há cogitar-se da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (privilégio), eis que, apesar da primariedade e dos bons antecedentes do réu, há nos autos expressiva quantidade de drogas apreendidas (75,38 gramas de cocaína e 32,59 gramas de maconha) e prova robusta da dedicação habitual e reiterada do agente a atividades criminosas (sobretudo ligadas ao narcotráfico), consoante se infere, especialmente, do conteúdo extraído do celular por ele utilizado (cf. laudo de fls. 103/147 e informação policial de fls. 189/199).

Vale registrar, nesse ponto, o firme posicionamento do Colendo STF de que a quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para o afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (RHC nº 138.117-AgR - 1ª Turma - Rel. Min. Rosa Weber - publ. 06.04.2021), já que sua utilização para tal fim somente pode ocorrer quando esse vetor estiver conjugado com outras circunstâncias do caso concreto, tal como se dá nos presentes autos.

Torno as reprimendas, pois, definitivas, diante da ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

O Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 111.840/ES (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27.06.2012), declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 (com a redação dada pela Lei nº 11.464/07), por entender que a norma contraria a CF/88, especificamente no que diz respeito ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI), para admitir a imposição, aos condenados por crimes hediondos e a eles equiparados, de regime prisional inicial diverso do fechado.

Desse modo, considerando especialmente a primariedade do agente, as circunstâncias judiciais favoráveis e o próprio quantum da reprimenda, a pena privativa de liberdade a ele imposta será cumprida inicialmente em regime semiaberto, que se afigura necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Confira-se:

“Nos crimes de tráfico de entorpecentes, a escolha do regime prisional inicial deve levar em consideração a quantidade da pena imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e as demais peculiaridades do caso concreto (como a natureza e a quantidade de drogas apreendidas, por exemplo), para que, então, seja escolhido o regime carcerário que, à luz do disposto no art. 33 e parágrafos do Código Penal, se mostre o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado” (STJ - AgRg no HC nº 322.686/RJ - 6ª Turma - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - j. 25.08.2015 - DJe 11.09.2015).

Outrossim, no tocante à substituição da pena carcerária por penas restritivas de direitos, o Excelso Pretório, nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS (Rel. Min. Ayres Britto, j. 01.09.2010), declarou inconstitucional dispositivo da lei que vedava essa conversão (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

E o Senado Federal, em observância à decisão do Colendo STF, por força da Resolução nº 05/2012, suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" contida no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Todavia, a mencionada substituição de penas revela-se incabível, no caso em exame, tendo em vista o próprio montante da pena corporal aplicada (superior a 4 anos de reclusão), que não se amolda ao disposto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação e CONDENO o réu ALEX ALBERTO BENEDITO à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Faculto ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Oportunamente, expeça-se mandado de prisão, observado o regime prisional inicial fixado.

Tendo em vista sua manifesta origem ilícita, decreto o perdimento do numerário e do objeto apreendidos (cf. auto de fls. 07/08 e guia de fl. 70), com fundamento no art. 63 da Lei nº 11.343/06.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

Araraquara, 17 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA